

1500327-69.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAINAN DOS SANTOS PINTO

Data da Audiência:

24/05/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500327-69.2021.8.26.0571 - Controle 2021/000315

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAINAN DOS SANTOS PINTO

Data da Audiência:

24/05/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Kainan dos Santos Pinto. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Márcio Ferreira e Márcio Roberto da Silva Queiroz arroladas pelas partes. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(^a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, O réu foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", c. c. o artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 61, II, "j", do Código Penal, pois, no dia 02 de março de 2021, por volta das 15h07min, na Praça Peixoto Gomide, centro, nesta cidade e Comarca de Itapetininga, nas proximidades dos três estabelecimentos de ensino localizados no centro da cidade, trazia consigo e guardava, para fornecimento e entrega a consumo, ainda que gratuito, 21 (vinte e uma) porções de

cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 4,27g (quatro gramas e vinte e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 158/159). A denúncia foi recebida em 18/11/2021 (fls. 160). O acusado foi citado por edital, não compareceu em juízo e não constituiu advogado, motivo pelo qual o processo e o prazo prescricional foram suspensos com fundamento no artigo 366 do CPP (fls. 168). Após, o réu foi localizado e pessoalmente citado (fls. 197). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), constatação (fls. 15/16) e pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 79/81). A autoria também foi devidamente demonstrada. Vejamos. Em solo policial, o réu admitiu que trazia consigo pedras de "crack", que guardava a pedido de outra pessoa, pois devia dinheiro a ela. Contou que foi abordado pelos policiais, que encontraram a droga em sua mochila (fls. 07). Interrogado em Juízo, o acusado disse que guardava as porções para terceiro. Alegou que as vendas eram efetuadas por outra pessoa. Beneficiava-se através de uma comissão e de algumas doses para uso próprio. A prova oral também é suficientemente segura ao incriminá-lo. De fato, diz a denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento próximo à praça do "Cofesa", local conhecido na cidade como ponto de venda e uso de drogas, instante em que receberam a informação de um transeunte de que um casal praticava tráfico na referida praça. Em posse das características físicas do casal, os policiais, de imediato, identificaram a ambos, instante em que resolveram abordá-los. Ao perceber a aproximação, a mulher conseguiu empreender fuga, não sendo detida. O acusado, porém, avançou na equipe, não permitindo a abordagem. Não obstante, durante a diligência, foram localizadas com ele, dentro de sua mochila, as 21 (vinte e uma) porções de crack acima mencionadas. Ele portava, ainda, a quantia de R\$ 40,80 (quarenta reais e oitenta centavos). Todas as porções estavam devidamente embaladas, prontas para a imediata alienação. Ante a inequívoca situação de flagrância, o acusado foi preso e conduzido a solo policial para as demais providências. Pois bem. Agora, o policial Márcio afirmou que patrulhava pelo local quando recebeu informação que dizia da prática do tráfico em frente ao "Cofesa". Nas proximidades, já viram o casal alvo da denúncia. O réu, de pronto, partiu contra a guarnição. Houve contenção e revista. O réu trazia consigo cerca de R\$ 40,00 e, na bolsa, as porções de "crack". O policial Márcio Roberto fez coro às palavras de seu colega. Assim, a prova é firme ao incriminar o acusado. Registre-se que nada está a indicar que as testemunhas estejam a prejudicar inocente ou a fantasiar sobre as circunstâncias do crime. Suas palavras foram firmes, harmônicas e coerentes, de modo que merecem todo crédito. Ademais, o réu confessou que trazia consigo porções de "crack" e que as guardava para outra pessoa, ou seja, admitiu a prática do tráfico de drogas (fls. 07). Dessa forma, os fatos narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovados. Impõe-se, pois, a integral procedência da ação. Passemos, então, à análise da pena. Observo que o réu não ostenta maus antecedentes e é primário (fls. 32/34). Na segunda fase, a pena deverá ser agravada com fundamento no artigo 61, II, "j", do Código Penal. Já na terceira fase, a pena deverá ser aumentada, pois o crime foi praticado nas proximidades de três estabelecimentos de ensino (art. 40, III, da Lei 11.343/06). Por fim, cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. O regime inicial poderá ser fixado no aberto e nada impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, com decretação do perdimento dos valores apreendidos. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: A Defensoria Pública representa o acusado, que foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 c. c. o artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06. Ocorre que a pretensão persecutória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao acusado, pelas razões a seguir. (I) DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11343/06: A acusação se baseia, tão somente, em apreensão de

diminuta quantidade entorpecentes e como o réu não foi preso mantendo contato com pessoas, mas apenas – de acordo com os depoimentos – na posse de pequena quantidade de entorpecente (menos de 5g de crack), a conduta mencionada melhor se adequa àquela prevista no art. 28 da lei de drogas. A distinção do tipo legal do artigo 28 da Lei n. 11.343 do tipo penal do art. 33 da mesma lei se dá por força do elemento subjetivo específico “para consumo pessoal”. Conquanto o tipo do art. 28 contenha mais elementos subjetivos, não cabe à Defesa provar esse fim específico, mas sim cabe ao acusador demonstrar que esse fim não existia; e isto por força do princípio da presunção de inocência e da fórmula do in dubio pro reo, que determinam que se presume que o acusado incorreu no tipo penal menos grave enquanto o conjunto probatório não indicar seguramente no sentido contrário. Ainda, o fato de parte das substâncias estar embalada individualmente nada indica: se alguém vende a droga fracionada, alguém a compra também fracionada, de modo não há como inferir a mercancia apenas em razão desta circunstância. Destaque-se, por fim, que apesar de o réu ter mencionado que guardava a troca para terceiro, também disse que consumia os entorpecentes, pois fazia uso de crack. Desta maneira, diante da ausência de evidências de que o réu visasse comercializar e obter lucro (circunstância inerente ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06) deve prevalecer o entendimento de que a classificação jurídica correta para a conduta atribuída a ele é a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, devendo-se operar, portanto, a desclassificação, com suas consequências legais. (II) DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06. De rigor reconhecer-se que o aumento gerado pelo art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 deve ser afastado, já que a circunstância prevista no referido dispositivo legal não restou devidamente configurada na hipótese. Em primeiro lugar, nenhuma das testemunhas ouvidas mencionou que o local da abordagem era próximo às escolas. Não houve qualquer indicativo de que no local houvesse aglomeração de pessoas ou de que tivesse aula acontecendo nas proximidades. Não restou demonstrada a intenção do acusado em praticar a comercialização do entorpecente se valendo da existência de escola no local. O objetivo na norma é punir mais severamente aquele que não se aproveita da aglomeração de pessoas para a disseminação de drogas – o que claramente não se deu na hipótese. Aliás, esse é o entendimento tanto do STF (HC 124483) quanto do STJ (HC 451.260/ES). Assim, a causa de aumento deverá ser afastada. (III)- DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. Requisitos legais preenchidos. Na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado é primário e tem bons antecedentes. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da primariedade do denunciado. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio

Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida”. (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no

art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. (IV) TESES SUBSIDIÁRIAS. Em caso de condenação, na primeira fase da dosimetria das reprimendas, cabe ressaltar que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal, eis que a culpabilidade da ação do acusado não extrapola aquela inerente ao respectivo tipo penal, não tendo havido, ainda, maiores consequências da prática delitiva. Outrossim, na segunda fase, pleiteia seja considerada a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do CP) e afastada a agravante pleiteada na denúncia, visto que a pandemia em nada influenciou para a prática delitiva. Finalmente, quanto ao regime inicial, requer que seja fixado regime inicial aberto de cumprimento da pena, nos termos do art. 33 do Código Penal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Pugna-se, por fim, com fundamento no art. 8º, item 2, 'h', da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

Vistos. KAINAN DOS SANTOS PINTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06, c.c. o art. 61, inc. II, alínea “j”, do Código Penal, porque, no dia 02 de março de 2021, em período de anormalidade – Pandemia e nas imediações dos três estabelecimentos de ensino localizados no centro do município, por volta das 15 h e 07 min, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e uma porções de “crack”, com peso de 4,27 gramas. Notificado por edital, fls. 149, o Réu apresentou defesa preliminar, fls. 158/159. A denúncia foi recebida, fls. 160, e o Réu, citado por edital, fls. 163, não compareceu em Juízo e não constituiu defensor, deste modo o feito foi suspenso, fls. 168. O Órgão Acusador apresentou embargos de declaração, fls. 171/172, o recurso foi recebido e acolhido, uma vez que havia pedido de prisão preventiva, fls. 175. O mandado de prisão foi cumprido, fls. 178/181. Após, o Réu foi citado, fls. 197. Durante a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório do Acusado (gravação por videoconferência). Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a desclassificação e a aplicação de benefícios. É o relatório. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade do delito acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 10/11, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 12, bem como no Laudo de Constatação, fls. 15/16 e de Exame químico-toxicológico n. 71307/2021, fls. 79/81, constatando-se a presença do princípio ativo cocaína. Márcio Ferreira e Márcio Roberto da Silva Queiroz, policiais militares, disseram que estavam em patrulhamento nas proximidades da praça do Cofesa, local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, quando receberam informações da prática do comércio ilícito por um casal; foram ao local e encontraram o Réu e uma mulher, tendo o Acusado, ao perceber a ação policial, avançado contra os policiais, momento em que a mulher empreendeu fuga. Durante a abordagem foi necessário o uso de força física moderada para contê-lo e os policiais localizaram dinheiro com o Réu e, dentro da mochila, porções de “crack”. Kainan dos Santos Pinto, Réu, ao ser interrogado, disse que morava na rua e usava drogas; segurava os entorpecentes para a venda e recebia parte das drogas como retribuição. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a condenação é medida que se impõe. Com efeito, os policiais estavam em patrulhamento quando receberam informações sobre o tráfico de entorpecentes e, em diligências, depararam-se com o Réu, que, ao vê-los, avançou contra as testemunhas, mas, após ser dominado, com ele houve a apreensão de dinheiro e de porções de “crack”. Houve apreensão de vinte e uma porções de “crack”, com peso de 4,27 gramas, quantia e forma de partilha compatíveis com o comércio ilícito, notadamente se considerado for que o Réu estava em local conhecido pelo comércio espúrio, às 15 h e 30 min. Ademais, o Réu confessou o delito e, embora tenha afirmado que não pretendia obter lucro, mas apenas receber parte para seu uso, essa circunstância, além de ser irrelevante, já que se demonstrou a destinação das substâncias a terceiros, não restou demonstrada. Por fim, os policiais deram testemunhos firmes, coerentes, e descreveram de forma isenta os fatos como ocorreram. No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais e agentes da lei, há que se considerar que,

por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos. Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, condutas estas que configuram a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de trazer consigo e guardar, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede integralmente. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. - Art. 59, "caput", do Código Penal: Considero boas as circunstâncias judiciais, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. Art. 61 e art. 65, do CP: O Réu confessou, logo faz jus à atenuante. Todavia, na segunda etapa, as atenuantes não tem o condão de minorar a reprimenda a quem do piso legal. Esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". - Art. 68, do CP: Considerando-se a quantidade de entorpecentes, aplico a causa de diminuição de pena e a reduzo em 2/3. Fixo-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, que torno definitiva. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa "empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo", pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no último dispositivo legal acima mencionado. Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). O Superior Tribunal de Justiça já vem se alinhando àqueles entendimentos, conforme se viu no julgamento do Habeas Corpus 176.919/DF, onde foi concedida a ordem para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e para substituir esta por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2010, DJe 13/12/2010). Na hipótese, o réu havia sido condenado por tráfico de drogas, lhe sendo imposta uma sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, tendo sido reconhecida a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais, o Réu poderá cumprir a pena no regime aberto, já considerada a detração. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Preenchidos os requisitos previstos nos

incs. I, II e III, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, e limitação de fim de semana. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar KAINAN DOS SANTOS PINTO, qualificado nos autos, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário - mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir no art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade, e limitação de fim de semana. Decreto a perda dos valores apreendidos. Deixo de condenar o Réu nas custas, ante a pobreza presumida. O Réu respondeu preso ao processo em virtude do descumprimento das medidas cautelares, todavia, neste momento, ausentes as razões da custódia cautelar, poderá interpor eventual recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura, com urgência. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 24 de maio de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA